

1502813-38.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO TRÁFICO

Há provas da autoria e materialidade.

A materialidade do tráfico vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls.10/11 ; foto de fls. 12; auto de constatação de fls.16/21, exames químicos toxicológicos positivos para substancia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502813-38.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502813-38.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2299523/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 21184606 - 01º D.P. GUARULHOS, 3739/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2299523 - 01º D.P. GUARULHOS, 2299523/2021 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ENRIK SOARES DA CRUZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

LUIZ ENRIK SOARES DA CRUZ E VÍTOR KENZO DORTA YAMASHITA foram denunciados e estão sendo processados por violação ao artigo 33 caput e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, porque: 1) no dia 03 de novembro de 2021, em horário incerto, à tarde, no interior de um armário localizado na Rua Juquitiba, próximo ao imóvel de n. 501, Macedo, nesta cidade e Comarca de Guarulhos/SP, tinham em depósito, para fins de tráfico, 218 porções de cocaína, com peso líquido de 88,2g; 530 unidades de crack, com peso líquido de 111,45g e 180 porções de maconha, com peso líquido de 290,12g, substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 2) em data incerta, mas até 03 de novembro de 2021, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas; 3) no dia 03 de novembro de 2021 ofereceram vantagem indevida, consubstanciada em dinheiro e drogas, aos guardas civis para omitirem ato de ofício.

Oferecidas as defesas preliminares, a denúncia foi recebida, os réus foram citados, durante a instrução foram colhidos os depoimentos de 2 testemunhas, uma informante e os réu foram interrogados.

Em memoriais, o MP (fls. 407/410) pugnou pela parcial procedência, afastamento do tipo penal previsto no artigo 35 do CP e condenação em relação aos demais delitos.

A Defesa do réu Victor (fls. 411/429, 437/438) requereu a absolvição do réu, pois, as provas são ilícitas, já que oriundas da atuação da guarda municipal, subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas, afastamento do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei 11.343/09, incidência do tráfico privilegiado, aplicação de pena restritiva de direito, e ainda ANPP.

A Defesa do réu Luiz (fls. 430/435 e 440/441), requereu a absolvição, em razão das provas serem oriundas da atuação ilegal dos guardas municipais, subsidiariamente, ausência de provas para condenação, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

DO TRÁFICO

Há provas da autoria e materialidade.

A materialidade do tráfico vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls.10/11 ; foto de fls. 12; auto de constatação de fls.16/21, exames químicos toxicológicos positivos para substância entorpecentes de fls. 168/177.

A autoria também é certa.

O réu Luis, na fase policial negou sua participação no ilícito, disse que o réu Victor mostrou para os guardas onde as drogas estavam, negou a corrupção e afirmou que os guardas pediram dinheiro para ele. Em juízo, negou o crime, disse que estava com dinheiro fruto de venda de pano de prato, que na menoridade já teve passagem, viu os policiais com o Victor e com as drogas, que eram de Victor, negou a oferta de dinheiro, não conhecia os guardas municipais, realmente o local dos fatos era um ponto de drogas. Negou que procurou fugir. Alegou que quando era menor de idade era comprometido com o tráfico, por isto eles tinham sua foto como traficante, acredita que é em razão da menoridade, negou conhecer o corréu, negou tê-lo apontado aos guardas municipais, alegou que o dinheiro era fruto da venda de pano de prato do dia anterior, negou ter oferecido dinheiro aos guardas, ou que

eles tivessem lhe solicitado dinheiro.

O réu Victor, na fase policial confessou o crime, disse que "trabalha" para o tráfico (fls. 5), negou a corrupção. Em juízo, Victor negou o crime, disse que no dia que foi preso, tinha acabado de voltar do serviço com seu pai e no dia foi comprar droga, é viciado, estava no lugar errado na hora errada. Foi pegar a droga com um rapaz, que não é o corréu. Indagado com qual dinheiro, já que o dinheiro estava com o corréu, alegou que tinha R\$ 10,00. Negou que tivesse apontado a localização das drogas. Foram os guardas que o levaram até a droga, não os levou até o armário com as drogas. Não conhecia os guardas, não sabe porque eles o acusaram. Negou tenha sido abordado a tarde. Negou estivesse com celular ligado, estava desligado, não recebeu ligação dizendo guarda a bomba. Não sabe quem o apontou para a polícia. Trabalha com o genitor carregando e descarregando carro.

A testemunha Waldecir, sob o crivo do contraditório, disse: naquela rua existe um palco municipal o Tomeuzão, ao lado uma escola, razão pela qual estava em patrulhamento pela região e viu o réu Luiz andando, numa curva e ao ver a viatura tentou sair, o abordou encontrou uma porção de dinheiro, ele disse que ele trabalhava com a tia dele, ela apareceu de branco e disse que não sabia deste dinheiro, o réu Luis confessou que estava com o dinheiro da mercancia e que a droga estava com outra pessoa, ai ele ofereceu dinheiro para ele, deu a volta encontrou o corréu Vítor e este os levou ao local que as drogas estavam, diante dos fatos conduziu todos para Delegacia de Polícia. O réu Luis disse que lhe pagaria R\$ 3000,00 para ele o liberar, ele não tinha todo este valor, tinha menos, mas lhe ofereceu R\$ 3000,00 para libera-lo.

A testemunha Pedro disse estava em patrulhamento se deparou com o réu Luiz num ponto de drogas, ele ficou nervoso, tinha aproximadamente R\$ 500,00 ou R\$ 600,00, ele falou que vendia pano de prato, depois disse que o dinheiro era fruto de venda de droga, que estava com o dinheiro da venda de drogas e o colega com a carga, referindo-se às drogas, que iria lhe pagar R\$ 3000,00 para não ser preso, na sequencia o réu Luis o levou até o corréu Vítor e este apontou a localização da droga, estava num armário, tinha 3 guardas e 2 cães, localizaram as drogas, os dois estavam muito próximos pelo meio da comunidade menos de 2 minutos voce ia num local a outro, as viaturas foram no apoio, comunicou a central da guarda, não tem vínculo com a Polícia Militar, acredita que a viatura da época, antiga não tinha GPS, atualmente possuem, trabalha 12 anos na guarda civil municipal, na sua carreira já recebeu propostas de suborno, poucas propostas. Esclareceu que quando disse do apoio de outras viaturas é para que as pessoas da comunidade não os impeçam de formalizar o flagrante, pois, é comum eles atacarem pedras, resgatarem o preso, mas eles não participaram do flagrante, em si, as drogas não estavam em poder de Victor, mas no armário apresentado por ele. Primeiro quem ofereceu dinheiro foi o réu Luiz, disse que pagaria R\$ 3000,00 reais para eles não o prenderem, Luis disse que já costumava fazer isso, pagar policial, depois, o réu Victor afirmou que entregaria a carga para eles não os levarem preso, referindo-se as drogas.

Pois bem, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que os réus foram surpreendidos guardando, tendo em depósito drogas. O réu Luis estava com o dinheiro das drogas em mãos e o réu Victor estava com as drogas em depósito, no armário, o réu Luis estava num local de venda de drogas, os dois estavam próximos, havia liame subjetivo entre os dois.

Insta consignar que não há que se falar em prova ilícita, por desvio de atividade dos guardas municipais. Com efeito, o julgado colacionado pela Combativa Defesa, não vincula o juízo, bem como não altera a natureza jurídica do flagrante, a legalidade da atuação dos guardas municipais, no caso em concreto.

O tipo penal do artigo 33 caput da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, entre os

verbos consta: guardar, ter em depósito, descrito na denúncia, estes verbos caracterizam o tráfico permanente, enquanto guarda ou tem em depósito, há flagrante delito.

Os dois guardavam, tinham em depósito a droga apreendida, enquanto o entorpecente estava guardado, o crime era consumado. Pois bem, no momento da localização das drogas que foi ocasional, os réus estavam em flagrante delito e os guardas municipais os prenderam em flagrante delito.

O artigo 301 do Código de Processo Penal reza: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito."

Os guardas municipais são qualquer do povo, podem efetuar a prisão em flagrante, como qualquer do povo.

Não houve desvio de finalidade, na atuação dos guardas, pois, eles não saíram para coibir o tráfico, mas em razão da existência de escola nas proximidades, no município que estão vinculados, estavam em trânsito regular, desenvolvendo ações de prevenção primária à violência conforme artigo 3º, inciso III; artigo 5ºXVI da Lei 13.022/2014 e se depararam com os réus em situação de traficância. O réu Luis estava num ponto de drogas, o ginásio Tomeu abandonado, no momento que os guardas se aproximaram o réu Luis estava com dinheiro, ele afirmou que os valores que trazia consigo era fruto de venda de drogas e os levou até o Victor que estava cerca de 30 metros numa linha reta, Victor era o guardião das drogas e apontou a localização, no momento que estava com os guardas o seu telefone tocou e o avisaram que os guardas estavam na região.

Logo após os guardas efetuarem o flagrante delito, conduziram os réus à Delegacia de Polícia na forma do artigo 5º, inciso XIV da Lei 13.022/2014.

Pois bem, não há que se falar nos frutos da árvore envenenada, decorrente de prova ilícita, porque, os guardas estavam no exercício regular das suas atribuições, ronda do patrimônio municipal, na rota encontraram Luiz num ponto de drogas, que se assustou e ficou temeroso, então pararam e o abordaram, oportunidade que este delatou o Victor, que era responsável pela guarda da droga, Luis apontou onde Victor estava, foram ao local, que era próximo, no qual Victor estava e este os levou até às drogas guardadas (180 unidades de maconha; 218 de cocaína; 530 porções de crack). Neste ponto reitero, crime permanente é aquele cuja consumação se perpetua no tempo, enquanto a pessoa guarda, tem em depósito, mesmo que esteja em local distinto da droga, está cometendo o crime de tráfico na modalidade guardar, ter em depósito, como no vertente caso.

Por derradeiro, a Constituição Federal no artigo 144, caput afirma: "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, (...)" e no parágrafo 8º, deste mesmo artigo há a autorização da criação e existência das guardas municipais, em conformidade com a Lei infraconstitucional, dentro do sistema de Segurança Pública, entendo que os Guardas atuaram observando o princípio da legalidade (artigo 37, caput da Constituição Federal), observando o artigo 301 do CPP e a Lei 13.022/2014.

De rigor a condenação de ambos os acusados.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

A quantidade de drogas apreendidas 928 porções; a quantia de dinheiro fruto da venda; R\$ 600,00 revelam que a conduta dos réus não foi eventual, porém, paira dúvidas sobre a estabilidade e permanência entre os dois acusados, razão pela qual na dúvida os absolvo desta imputação.

DA CORRUPÇÃO ATIVA.

Há provas suficientes da prática deste ilícito pelos réus.

O primeiro a oferecer vantagem indevida para os guardas não o levarem à Delegacia de Polícia foi o réu Luiz, que ofereceu R\$ 3000,00, tinha R\$ 600,00 e afirmou que teria o restante para paga-lo.

O segundo a oferecer vantagem indevida foi Victor, que ofereceu a mercadoria apreendida cerca de mil unidades de substância entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína.

As testemunhas não tem motivo para acusa-los injustamente, nenhum deles conhecia o réu Luis da menoridade, quando ele próprio disse que vendia drogas, era comprometido com o tráfico, não há qualquer indicativo de envolvimento destes agentes administrativos com os familiares dos réus, razão pela qual, impõe-se a condenação, diante da prova oral coligida.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

Aplica-se a regra do artigo 69 do Código Penal, entre o crime de tráfico e corrupção ativa, pois, são delitos autônomos, com vítimas, objetividades jurídicas, distintas, razão pela qual as penas devem ser somadas.

PASSA-SE À FIXAÇÃO DA PENA.

DO RÉU LUIZ ENRIK SOARES DA CRUZ

DO TRÁFICO.

Na primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando o envolvimento do réu na menoridade, na prática de atos infracionais equiparados a tráfico, cuja natureza jurídica não gera reincidência, mas revela o comprometimento pretérito do acusado com o meio infracional, esta vivencia revela a personalidade, a conduta social do acusado, logo, reflete nas circunstancias judiciais, nesse sentido Enunciado 33 do Fonajuc: "Os atos infracionais poderão ser valorados na fixação da pena-base, quando da análise das circunstancias judiciais artigo 59 do CP", e ainda, por força do artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena também deve ser majorada nesta fase, considerando quantidade de drogas, no total 928 porções de substância entorpecentes, mais a apreensão de R\$ 600,00 fruto da venda revelando que a quantia era maior, a variedade e natureza das drogas: crack, cocaína, maconha, e ainda o réu também não tem ocupação, lícita formal, embora faça bicos com o tio, quando este não o chama não tem outras atividade, assim, fixo a pena base em 7 anos de reclusão.

Na segunda fase, não há causa que autorize a mudança da pena, mantenho no mesmo patamar.

Na terceira fase, entendo que o réu não pode ser favorecido pela causa de diminuição de pena do art. 33, parágrafo 4º da Lei de Entorpecente, face comprometimento com o meio infracional, quantidade expresisva de dorgas e variedade não é entregue a custódia de incautos, novatos, aliás, o acusado tem experiencia desde a menoridade, na prática do tráfico, neste ponto destaco o Enunciado 32 do FONAJUC segundo o qual "havendo registro anterior de ato infracional praticado pelo réu, a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 poderá ser afastada", assim, não há incidência do privilégio, pois, não basta ser primário, imperioso não ter vivencia no meio criminoso, integrar uma estrutura criminosa, assim, resta a pena final de 7 anos de reclusão.

Adotando o mesmo critério fixo a pena de multa em 700 dias dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo cada dia-multa.

DO ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL.

Na primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando o envolvimento do réu na menoridade, na prática de atos infracionais equiparados a tráfico, conforme Enunciado 33 do FONAJUC: (nesse sentido Enunciado 33 do Fonajuc: Os atos infracionais poderão ser valorados na fixação da pena-base, quando da análise das circunstâncias judiciais artigo 59 do CP), assim, fixo a pena base em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda e na terceira fase, não há causa que permita a mudança da pena, restando a pena final, para este ilícito, de 2 anos e 3 meses de reclusão.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena de multa em 13 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Aplico a regra do artigo 69 do Código Penal, restando a pena final de: 9 anos e 3 meses de reclusão e a pena pecuniária de 713 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

DO RÉU VÍTOR KENZO DORTA YAMASHITA

DO TRÁFICO.

Na primeira fase, fixo a pena base acima do mínimo legal, por força do artigo 42 da Lei 11.343/06, considerando quantidade de drogas, no total 928 porções de substância entorpecentes, mais a apreensão de R\$ 600,00 fruto da venda revelando que a quantia era maior, a variedade e natureza das drogas: crack, cocaína, maconha, assim, fixo a pena base em 6 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante genérica ser menor de 21 anos na data dos fatos (artigo 65, inciso III, alínea d do CP), reduzo sua pena, e a passo para 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase, entendo que o réu não pode ser favorecido pela causa de diminuição de pena do art. 33, parágrafo 4º da Lei de Entorpecente, face comprometimento com o meio infracional, quantidade expressiva de drogas e variedade não é entregue a custódia de incautos, novatos, assim, não há incidência do privilégio, pois, não basta ser primário, imperioso não ter vivência no meio criminoso, integrar uma estrutura criminosa, assim, resta a pena final de 5 anos e 6 meses de reclusão.

Adotando o mesmo critério fixo a pena de multa em 550 dias dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo cada dia-multa.

DO ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo de 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante genérica ser menor de 21 anos na data dos fatos, logo, porém, a pena já foi fixada no mínimo legal, não podendo ir a quem deste valor nesta fase, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, assim, mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, não há causa que permita a mudança da pena, restando a pena final, para este ilícito, de 2 anos de reclusão.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena de multa em 10 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Aplico a regra do artigo 69 do Código Penal, restando a pena final de: 7 anos e 6 meses de reclusão e a pena pecuniária de 560 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Para os dois réus, o regime prisional é o inicialmente fechado.

De efeito, face circunstâncias judiciais desfavoráveis a ambos os réus, e ser este o único regime compatível com a natureza e um dos delitos equiparado a hediondo e que atende os fins da pena. De efeito, o Constituinte Originário no rol dos direitos fundamentais, visando o bem comum do cidadão massacrado com os efeitos do tráfico ilícito de entorpecentes no artigo 5º, inciso XLIII conferiu tratamento diferenciado a este ilícito, a Lei 8072/90 observando o Constituinte disciplinou o regime de cumprimento da pena, que é o inicial fechado. Insta consignar que o regime integralmente fechado foi considerado inconstitucional conforme teor da Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e não o inicialmente fechado. Pende consignar que o princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI da Lei Maior) deve ser observado em três fases, primeiro pelo Legislador, segundo pelo Judiciário na fixação da pena e novamente pelo Judiciário na fase de execução da pena. Pois bem, nos crimes hediondos e equiparados independente do valor da pena, primariedade ou não, o regime de cumprimento da pena é o inicial fechado, e a progressão de regime tem regra própria, trata-se do princípio da especialidade. Ora, o Legislador, ciente da necessidade de uma resposta social proporcional, observando o artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição da República (princípio da efetividade do direito), visando a repressão; a prevenção geral e especial norteou o juiz na fixação da pena em delitos desta natureza para o regime inicial fechado, que não é incompatível com a finalidade ressocializadora, que deve ser exigida na fase executória.

Pelos mesmos motivos incompatível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. A regra do artigo 44 do Código Penal é destinada a ilícito de pequeno e médio potencial ofensivo. Tráfico de entorpecentes é de elevadíssimo potencial ofensivo individual e geral. Insta consignar que a pena final dos réus é superior a 4 anos.

Prejudicado o pedido de ANPP.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR: 1) LUIZ ENRIK SOARES DA CRUZ por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 333, caput do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 9 (NOVE) ANOS e 3 (TRES) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado e à pena pecuniária de 713 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal; 2) VICTOR KENZO DORTA YAMASHITA por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 333 caput do Código Penal à pena privativa de liberdade de; 7 (SETE) ANOS e 6 (SEIS) MESES de reclusão sob o regime inicial fechado e à pena pecuniária de 560 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal. ABSOLVO LUIZ ENRIK SOARES DA CRUZ E VICTOR KENZO DORTA YAMASHITA da violação ao artigo 35, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado oficie-se o TRE.

Determino a perda do dinheiro apreendido em favor da União e a destruição das drogas apreendidas e dos aparelhos celulares, pois, não há nos autos prova da propriedade lícita destes, foram utilizados no meio criminoso, assim, determino a destruição na forma do artigo 123 do CPP.

Os réus estão presos preventivamente e deverão manter-se custodiados para recorrer, pois os pressupostos da prisão preventiva estão mais reforçados (artigo 312 e 313 do CPP), há nesta fase certeza de autoria e materialidade delitiva de crime equiparado a hediondo, o réu Luiz tem vivência no meio infracional pela prática de tráfico (Enunciado 34 do FONAJUC), não poderão apelar em liberdade, para preservar a ordem pública, bem como pelos fundamentos já exarados na decisão de fls. 363/367, item II, que reitero na íntegra, como razão de decidir.

Os réus são condenados às custas do processo.

Expeçam-se guias de execução provisória.

Oportunamente, oficie-se o TRE e archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA